

1500371-50.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... o local da abordagem, conhecido ponto de tráfico, além do dinheiro apreendido, trazem elementos suficientes de que os réus atuavam para o narcotráfico.

Dessa forma, entendo que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base do réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500371-50.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500371-50.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YASMIN DA SILVA GOMES e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

WESLEY DE PAULA SANTOS, JANDERSON RODRIGO DE JESUS e YASMIN DA SILVA GOMES foram denunciados por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Consta do incluso expediente que, no dia 21 de fevereiro de 2022, por volta das 14h30min, na Travessa Imbassai, 10 - Jd. Oratório, nesta cidade de Mauá, os acusados traziam consigo, para fins de tráfico, as substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 37-9, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia, os réus foram citados (fls. 197-9) e apresentaram respostas à acusação.

As testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente inquiridas. Por fim, interrogou-se os réus.

Em memoriais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal nos termos da denúncia, enquanto a Defensoria Pública, em favor do réu Janderson, suscita a nulidade da instrução por ofensa ao § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal. No mérito, em síntese, as defesas dos réus Wesley, Janderson e Yasmin buscam a absolvição ante a insuficiência de provas, ou, ao menos, a fixação das penas nos patamares mínimos, reconhecendo-se a menoridade relativa e o tráfico privilegiado (réu Janderson), a fixação de regime penitenciário inicial brando, além da substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos (réu Janderson).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Malgrado o esforço argumentativo da Defensoria Pública, a preliminar levantada não se sustenta. A questão atinente ao acordo de não persecução penal já foi devidamente afastada no momento oportuno, destacando-se a falta de requisito objetivo (fls.263-9).

No mérito, a acusação procede.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01-2), boletim de ocorrência (fls. 03-7), auto de exibição e apreensão (fls. 37-9), laudos de constatação (fls. 51-62), laudos de exame químico-toxicológico (fls. 187-95 e 319-31), além da prova oral colhida.

Comprovou-se a autoria.

Interrogada, na fase administrativa, a ré Yasmin (sic) "alegou ser usuário de drogas e disse-nos que na ocasião dos fatos estava subindo em direção à comunidade do Oratório com o fito de comprar drogas tendo pago vinte reais para uma menina. Que presenciou o rapaz de blusa azul (Wesley) abastecendo a biqueira na segunda vez em que a interroganda subiu na favela. Que com a aproximação das viaturas da PM, disse que Carol jogou uma sacola de drogas sob um veículo Fiat/Palio que estava estacionado e que em poder dela apenas foi encontrada uma porção de maconha" (fl. 21). Sob o contraditório, novamente negou o ocorrido. Disse que estava no morro e, em dado momento, gritaram "moiô", motivo pelo qual os quatro abordados saíram correndo. Uma menina de prenome "Carol", que estava com a sacola, correu junto e dispensou os entorpecentes embaixo de um carro. Na sequência, foi abordada pelo policial militar, enquanto Carol foi abordada por uma policial feminina. Não conhece os corréus, mas viu quando eles também correram. Não viu se eles estavam com as drogas (mídia digital).

O réu Janderson, de seu turno, na fase inquisitiva afirmou que (sic) "na tarde de hoje foi apenas buscar drogas na biqueira do Oratório, quando percebeu uma intensa correria provocada pela chegada de viaturas da PM, momento em que foi detido juntamente com outro rapaz. Que ao tentar fugir de bicicleta, esbarrou numa "moça" e seguidamente foi derrubado ao solo por um policial militar, mas afirmou que não trazia consigo drogas com ele. Outrossim, afirmou ter presenciado os policiais militares encontrarem drogas com o outro rapaz (Wesley) tendo ainda afirmado que a menina "Yasmin" estava distribuindo as drogas na biqueira" (fl.13). Em juízo, narrou que, durante o seu horário de almoço, foi até a "loja" comprar maconha. Pegou a maconha e, antes que pudesse pagar, gritaram "moiô". Diante disso, pegou sua bicicleta e saiu, mas acabou colidindo com uma das moças e foi abordado pelo policial. Negou ter jogado o estojo com as drogas (mídia digital).

O réu Wesley, na fase antejudiciária, alegou que (sic) "na data dos fatos foi

buscar drogas na pracinha tendo recebido uma porção de maconha de uma mulher parecida com "um menino". Alegou que ao ser abordado pelos policiais militares tinha apenas R\$ 50,00 no bolso e apenas uma porção de maconha. Alegou, por fim, ser usuário de drogas" (fl. 29). Durante a instrução, manteve a negativa. Relatou que estava no local com cinco porções de cocaína, uma porção de maconha e R\$ 50,00, porém negou ter dispensado a sacola com as drogas. Por fim, disse que não conhece a corré Yasmin, mas conhece o réu Janderson, que também não estava vendendo drogas, mas apenas o acompanhava para comprarem entorpecentes (mídia digital).

As versões apresentadas pelos réus, contraditórias entre si e com aquelas prestadas perante a d. Autoridade Policial, não merecem credibilidade.

Os policiais militares, na fase antejudiciária, historiaram que (sic) "estavam em patrulhamento preventivo ostensivo e de preservação da ordem pública quando receberam a notícia anônima veiculada pelo telefone 190 dando conta que um indivíduo estava vendendo drogas nas proximidades da Travessa Imbassai com José Carlos da Silva, Jardim Oratório, nesta cidade. Que ainda segundo a delação apócrifa chegou nova informação dando conta que uma mulher (cor branca, camiseta azul, bermuda branca e tênis de cor preta) também estava comercializando drogas ilícitas. Que com base nessas informações os patrulheiros se dirigiram até o local objeto da delação e juntamente com o apoio de outras viaturas realizaram um cerco (uma viatura ficou em cima do escadão e outra permaneceu embaixo dele) de modo que os policiais avistaram quatro indivíduos que ao perceberem a presença das viaturas policiais passaram a correr, mas foram prontamente detidos. Que antes de ser abordada o depoente CB PM Reis presenciou a flagranteada Yasmin da Silva Gomes (que trajava camisa azul e características que coincidiam com as fornecidas via rádio) dispensou ao solo uma sacola plástica de cor branca que continha drogas (30 pinos de cocaína, 3 frascos de lança-perfume, uma porção de maconha e 37 invólucros plásticos contendo substância similar à cocaína, além de R\$ 293,00 em dinheiro trocado), ao passo que em poder da averiguada Wesleyne Karolayne Alves dos Santos nada de ilícito foi encontrado. Durante a ação policial o SD PM Garcez abordou o investigado Janderson Rodrigo de Jesus Rosa Brasiliense que ao ver o cerco policial tentou evadir-se de bicicleta numa viela, mas ao ser detido largou no chão um pochete (de cor laranja e com três zippers) em cujo interior havia considerável quantidade de drogas (5 frascos de lança-perfume, 2 invólucros de cocaína, 38 porções de maconha e uma unidade ecstasy e R\$ 36,85 em moedas), sendo que ao ser revistado com mais minuciosamente foi encontrado nos bolsos de suas bermudas R\$28,00, uma porção de maconha, enquanto que durante a abordagem ao investigado Wesley de Paula Santos, ele dispensou no chão 90 de pedras de crack e 04 pinos de cocaína. Ao ser revistado minuciosamente 50 reais em dinheiro, uma porção de maconha e 05 frascos de cocaína que estavam dentro de sua carteira de preta" (fls. 08-11).

Em juízo, confirmaram integralmente o ocorrido. O policial militar Guilherme disse que o COPOM irradiou uma ocorrência de tráfico, motivo pelo qual se deslocaram até o local indicado. Na viela em questão, visualizou quatro pessoas e com a aproximação da viatura todos correram, porém conseguiu abordá-los. Viu que antes de serem detidos os suspeitos conseguiram dispensar os entorpecentes, que estavam armazenados em sacolas e em um estojo. Esclareceu que o local é um ponto de tráfico e que foi responsável pela abordagem de Janderson e Wesley. Afirmou que Janderson estava com uma bicicleta e um estojo laranja, que foi dispensado antes de ser preso. Wesley, por sua vez, estava com uma sacola. Tanto no estojo, quanto na sacola, foram encontrados entorpecentes e dinheiro. Em busca pessoal nos acusados, também apreendeu porções de droga, que informalmente os réus alegaram ser para consumo próprio. Sobre as demais drogas, eles afirmaram que não lhes pertenciam, porém visualizou o momento em que eles as jogaram no chão (mídia digital).

No mesmo sentido as declarações do policial militar Felipe, que informou estar em serviço quando recebeu informação via 190 sobre a ocorrência de tráfico de

entorpecentes praticado por quatro indivíduos. Fizeram, então, a incursão pelo local e conseguiram cercar os suspeitos. Seu parceiro acompanhou a abordagem dos dois rapazes, enquanto realizou a abordagem das moças. Quanto à ré Yasmin, viu que, pouco tempo antes de ser abordada, ela dispensou uma sacola que tinha em seu interior entorpecentes e dinheiro. Informalmente, ela disse que a droga não era dela. Esclareceu que com a outra moça nada foi localizado, entretanto, ela foi conduzida ao Distrito Policial para ser ouvida (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

No Distrito Policial, foi ouvida a testemunha Wesleyne Karolayne, a qual disse que (sic) 'por volta das 13:00 horas saiu do CRAIS de Mauá (programa de desintoxicação mantida pela Prefeitura local), mas ainda assim resolveu dirigir-se até uma pracinha localizada na Rua José Carlos da Silva e lá chegando por volta das 14:200 percebeu que a biqueira ainda não estava devidamente "abastecida". Algum tempo, cerca de quinze minutos aportou no local um rapaz pardo, bermuda e blusa azul) que chegou trazendo com ele uma sacola de cor branca e outra transparente. Disse também que outro rapaz que estava de bicicleta foi derrubado ao solo no qual já havia drogas espalhadas no chão. Que a depoente alegou ser usuária e resolveu sair correndo com a chegada das viaturas, pois temia que a "outra mulher jogasse o BO pra cima dela"' (fl. 12).

Ao final da instrução, necessária a condenação.

Observe-se que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, além de plenamente coerentes, estão em perfeita harmonia àqueles por eles prestados perante a autoridade policial. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que os policiais tivessem motivo particular, injusto, para incriminar falsamente os réus.

Além disso, as circunstâncias em que foram presos, em posse das drogas e dinheiro, a correspondência com as informações irradiadas pelo COPOM, bem como as versões contraditórias apresentadas pelos réus na fase administrativa e em juízo, autorizam o desate condenatório.

A quantidade de droga encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a variedade e a forma em que era transportada, o local da abordagem, conhecido ponto de tráfico, além do dinheiro apreendido, trazem elementos suficientes de que os réus atuavam para o narcotráfico.

Dessa forma, entendo que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal,

fixo a pena-base do réu Wesley 1/5 acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes (certidão de fls. 86-7 - proc. 1500134-21.2019) e da considerável quantidade de drogas apreendida - 45 porções de cocaína (31,4 gramas), 41 porções de maconha (93,6 gramas), 74 porções de crack (27,8 gramas), 8 frascos de lança-perfume e 1 porção de ecstasy - fator que justifica a majoração da reprimenda penal, na medida em que incrementa o potencial ofensivo à saúde pública (bem jurídico tutelado pela norma penal), revelando uma maior reprovabilidade da conduta dos agentes (STF, HC 73.097, rel. Min. Maurício Corrêa, HC nº 76.543-5, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC nº 35.539, rel. Min. Paulo Medina, HC nº 35.795, rel. Min. Nilson Naves, HC nº 35.159, rel. Min. Hamilton Carvalhido), perfazendo 06 anos de reclusão e 600 dias-multa. Para os réus Janderson e Yasmin, tecnicamente primários, suficiente o acréscimo de 1/6 pela quantidade de drogas apreendidas, atingindo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Sobre o potencial lesivo da quantidade de cocaína e crack apreendida:

"A cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes inesperadamente com pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2 g para um homem de 70 kg. No entanto, fumadores de base livre reportam uso de quantidades que excedem a 1 g. Em contrapartida, há casos em que se pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de 20 mg. Isto pode ser explicado pela ocorrência da tolerância reversa que se caracteriza ou pelo aumento da susceptibilidade ao aparecimento de convulsões em doses consideradas recreacionais ou por uma excitação aumentada obtida em doses menores em usuários crônicos, fato que pode ser explicado pela diminuição da biossíntese dos neurotransmissores, o que leva a uma potencialização dos efeitos excitatórios." (Passagli, Marcos; Toxicologia Forense - Teoria e Prática, 5ª ed., Millennium: Campinas, 2018 - pg. 180-1).

Ainda, quanto a possibilidade de utilização de uma das condenações, transitada em julgado, como maus antecedentes:

"(...) é possível que sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e a segunda como reincidência, quando distintos os fatos geradores de cada uma." (HC 344.979/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016).

"Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena." (HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013).

Na fase intermediária, aumento a reprimenda do réu Wesley em mais 1/3, diante da reincidência específica (certidão de fls. 86 e 318 - proc. 007588-62.2015), totalizando 08 anos de reclusão e 800 dias-multa. De outro lado, tendo em vista a atenuante da menoridade relativa para os réus Janderson e Yasmin (18 anos), suas penas retornam ao patamar mínimo de 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

A reincidência específica de Wesley justifica referida fração de aumento, já que maior o desvalor da conduta. Neste sentido, precedente do e. Superior Tribunal de Justiça:

"A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)" (HC nº

257.571/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18/02/2014).

Não deve incidir, no caso concreto, para os réus Yasmin e Janderson - Wesley é reincidente - a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Não se desconhece que a quantidade do entorpecente, nos termos da Repercussão Geral no ARE nº 666.334/AM, rel. Min. Gilmar Mendes, deve ser ponderada em apenas uma das fases da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem.

Todavia, diante das circunstâncias do delito - os réus traziam consigo considerável quantidade e variedade de entorpecentes, foram presos em flagrante em local conhecido como ponto de tráfico, notoriamente dominado por facções criminosas, portanto sem espaço para "iniciantes"; além de não comprovarem, de forma idônea, o exercício de atividade lícita - parece-me claro o acentuado envolvimento no comércio de drogas, ou seja, a não ocasionalidade da conduta. Nota-se, ainda, que a ré Yasmin já respondeu a processo pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico (fl. 82 e consulta ao proc. 1502162-53.2019.8.26.0348 no ESAJ) e o réu Janderson, pela prática de atos infracionais análogos ao crime de roubo (fl. 95 e consulta aos procs. 1500158-43.2019.8.26.0348 e 1501628-75.2020.8.26.0348 no ESAJ). Evidente, assim, que se dedicam às atividades criminosas.

Nessa linha, posiciona-se o e Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. Os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 1873094/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020)

Repita-se que, nesta etapa, não há bis in idem na valoração da quantidade de drogas, já que tal circunstância foi utilizada apenas supletivamente, conjugada com outros vetores do caso concreto, para o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Ainda sobre o redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. ANÁLISE DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE SER INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. [...] 3. A conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a

dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010. [...] (STF HC 121.057/SP Rel. Min. Luiz Fux j. 25.02.14 DJU 18.03.14).

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA, MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O §4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes dispõe a respeito da causa de diminuição da pena nas frações de 1/6 a 2/3 e arrola os requisitos necessários para tanto: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividades criminosas e não à organização criminosa. 2. Consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de ser utilizado mercê de, como visto, haver elementos fáticos conducentes a conclusão de que o paciente era dado à atividade delituosa. 3. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções 'hominis' ou 'facti', pelo juiz, para decidir sobre a procedência do 'ius puniendi', máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como 'a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias'. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 4. Deveras, o julgador pode, mediante um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 5. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. In casu, o Juízo de origem ponderou a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (1,82g de cocaína pura, 8,35g de crack e 20,18g de maconha), destacando a forma como estavam acondicionadas, o local em que o paciente foi preso em flagrante (bar de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. [...] 6. Os fatos que deram ensejo à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Tóxicos são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Paciente às atividades criminosas. 7. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados

ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. [...] (STF HC 109.236/SP Rel. Min. Cármen Lúcia j. 13.12.11 DJU 14.23.12).

Definem-se, assim, as condenações em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa para o réu Wesley, e 05 anos de reclusão e 500 dias-multa para os réus Janderson e Yasmin.

O valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica dos réus.

Registre-se que o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 44 da Lei 11.343/06, nas partes em que se vedava a concessão de liberdade provisória (HC n. 104.339, rel. Min. Gilmar Mendes) e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (HC n. 97.256, rel. Min. Ayres Britto), bem como do parágrafo 1º do art. 2º da Lei n. 8072/90, que impunha o regime inicial fechado (HC n 111.849, rel. Min. Dias Toffoli).

Todavia, a gravidade in concreto do delito, considerando a quantidade, assim como o alto potencial lesivo da cocaína e do crack para saúde pública, além dos antecedentes dos réus, indica um grau acentuado de culpabilidade, de forma que o regime inicial fechado mostra-se necessário para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. Possibilidade de fixar regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.Ordem denegada." (STF - HC 119.515/AC - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 03.12. - DJU 10.12.13)

Pelo mesmo motivo, não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, insuficiente para prevenção e reprovação da conduta.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR o réu WESLEY DE PAULA SANTOS, qualificado nos autos, a cumprir pena de 08 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar 800 dias-multa, no patamar mínimo; e os réus JANDERSON RODRIGO DE JESUS e YASMIN DA SILVA GOMES, qualificados nos autos, a cumprir, cada um, a pena de 05 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar 500 dias-multa, no patamar mínimo, todos por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Denego ao réu Wesley o apelo em liberdade, mantidos os fundamentos da custódia cautelar.

Faculta-se aos réus Yasmin e Janderson o apelo em liberdade.

Transitada em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Com o trânsito em julgado, oficie-se para a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, bem como oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência dos valores apreendidos (fls. 154-9) ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD.

Cobre-se, com urgência, resposta ao ofício encaminhado à Autoridade Policial (fl. 127 e 132). Com a resposta, abra-se vista ao Ministério Público.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 06 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA